

1500464-22.2021.8.26.0613

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: WYLDENSOR MARTINS SOARES

Comarca: São José do Rio Pardo

Foro: Foro de São José do Rio Pardo

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 08/02/2022

... probatório. O réu admitiu a prática de tráfico de drogas para manter o próprio vício. A mesma versão foi apresentada também ao delegado de polícia. Os dois policiais que sequer são desta cidade e a prática do tráfico ali ocorre ao contrário do que o acusado tentou fazer crer. O traficante é quem fica ali na praça servindo usuários e veículos e não veículos se dirigem ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Pardo

Foro de São José do Rio Pardo

1ª Vara

Praça dos Três Poderes, nº 3, Sao Jose do Rio Pardo-SP - cep 13720-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500464-22.2021.8.26.0613 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500464-22.2021.8.26.0613

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2351607/2021 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 22156676 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 1150/21/200 -

DEL.SEC.CASA BRANCA, 2351607 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 1150/21/200 -

DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Vinícius da Silva Ernesto Abrão

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). WYLDENSOR MARTINS SOARES

Vistos.

Trata-se de ação penal em desfavor de Vinícius da Silva Ernesto Abrão, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, eis que no dia 27 de dezembro de 2021, por volta das 22h10min, na Praça João Batista Ribeiro de Lima, Vale Redentor, nesta cidade e comarca, vendia e trazia consigo, nas dependências de recinto onde

realizavam diversões de qualquer natureza, 01 (uma) porção de maconha, pesando 3,00 gramas; 02 (dois) invólucros plásticos contendo cocaína, pesando 1,50 grama; e 33 (trinta e três) porções de crack, pesando 8,00 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia de págs. 72/74, veio amparada no Inquérito Policial - Prisão em Flagrante - de págs. 01/67.

O réu foi notificado (págs.130) e apresentou defesa preliminar (págs. 81/87), aduz, em síntese, a primariedade do réu, alega que as drogas não são de sua propriedade e as desconhece. Requer a improcedência da denúncia, bem como a liberdade para que o réu recorra em liberdade.

A denúncia foi recebida aos 18 de janeiro de 2022, oportunidade em que fora designada audiência de instrução. (págs. 98/100).

Durante referida solenidade foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, bem como foi procedido ao interrogatório do acusado, conforme termo e mídia anexada ao SAJ - pg. 149/150.

Na fase do art. 402 do CPP nada foi requerido, passando-se prontamente aos debates.

Em debates, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal. A materialidade está demonstrada no auto de apreensão de pgs. 140/148. O acusado mudou totalmente a versão apresentada na fase inquisitorial dizendo que estava no local apenas para comprar droga. A versão do acusado na tentativa de se esquivar da acusação não encontra respaldo probatório. O réu admitiu a prática de tráfico de drogas para manter o próprio vício. A mesma versão foi apresentada também ao delegado de polícia. Os dois policiais que sequer são desta cidade e a prática do tráfico ali ocorre ao contrário do que o acusado tentou fazer crer. O traficante é quem fica ali na praça servindo usuários e veículos e não veículos se dirigem ao local para fornecer drogas aos usuários que ali permanecem. Os policiais nem são desta cidade e nem conheciam o réu e não têm nenhum interesse em incriminar o réu. Nas pgs. 132/133, 3 meses antes, o réu tinha sido surpreendido praticando o tráfico de drogas na mesma praça e só não permaneceu preso porque foi beneficiado com a liberdade provisória. Embora primário o réu tinha consigo 3 drogas diferentes devendo ocorrer aumento de pena pela variedade de drogas. Não faz jus à minorante, pois não exercia atividade lícita e tinha sido surpreendido praticando tráfico na mesma praça, dedicando-se à atividade criminoso. Não obstante trate-se de réu primário deve iniciar o cumprimento da pena em regime fechado.

A Defesa, por sua vez, sustenta que o réu não confessou o crime espontaneamente, pois ficou com medo. As demais drogas não podem ser atribuídas ao réu porque a praça é pública e nada indica que a droga era de propriedade do réu que apenas estava passando pelo local. O réu foi abordado e não ofertou resistência. Destaca a primariedade do réu, a atividade lícita como pedreiro e a residência fixa com seus pais. Não haveria qualquer outra ação penal em seu nome. O réu não pode ser responsabilizado pelas drogas abandonadas em local público, abandonada pelos órgãos públicos. Requer a absolvição pela insuficiência de provas, aplicando-se o princípio in dubio pro reo para absolver o réu. Alternativamente, requer a desclassificação para os moldes do art. 28 da Lei de Drogas, pois o réu é dependente de drogas por muitos anos e estava tentando se tratar. Requer, ainda, o reconhecimento do tráfico privilegiado, invocando a presunção de inocência. Pugna, ainda, pelo direito de responder ao processo em liberdade até o trânsito em julgado.

DECIDO.

1 -) SÍNTESE PROBATÓRIA

1.1 -) Das provas da materialidade.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão do inquérito policial (págs. 06), pelo auto de constatação preliminar (págs. 13) e pelos laudos periciais de págs. 140/148. Tais documentos demonstram massa líquida dos ilícitos apreendidos e a quantia apreendida na operação.

Houve, pois, modificação do mundo naturalístico pela conduta, restando atendido o princípio da materialização do fato.

2 -) Das provas da autoria.

Thiago Castro da Silva relata que na referida data realizavam pratulhamento preventivo em São José e na rua existe uma praça e visualizaram um veículo Volkswagen de cor preta fazendo contato com o réu. O veículo evadiu-se. O réu foi abordado com 33 porções de crack, duas porções de cocaína e uma porção de maconha. Ele tinha R\$ 55,00 em notas fracionadas de R\$ 5,00 – R\$ 10,00 – R\$ 20,00 e R\$ 2,00. Ele disse que estava traficando para sustentar o próprio vício. Trabalha no tático ostensivo rodoviário numa área de quase 900 km. Não conhecia a praça do Vale do Redentor. Os policiais informaram que naquela praça ocorre o tráfico de drogas. Não havia famílias no local. Era mais de 22:00 horas. O réu estava entregando algo na rua. Quando ele viu a viatura ele correu. Ele estava na calçada da praça.

Daniel Messias de Mello Carmo informa que estavam em patrulhamento juntamente com as equipes de moto no bairro Vale do Redentor e encontraram o réu entregando algo para um Gol Preto. Ele entrou na praça que é grande e pouco iluminada. O réu foi abordado e tinha uma pochete com maconha e crack, além de dinheiro. Ele falou que estava traficando no local em troca de drogas. Ele não aparentava que estivesse sob efeito de entorpecentes. Não conhecia o réu. O condutor do Gol Preto conseguiu se evadir. No horário da ocorrência estava apenas o pessoal do tráfico ali. Os civis, pessoas de bem, não costumam transitar ali até porque é pouco iluminada. Trabalha na região. Sabe que o local é ponto de venda de drogas. Nunca tinha visto o réu antes. Geralmente fica uma pequena quantidade de drogas na pochete e a maior parte fica escondida, não conseguem saber onde fica porque é lugar totalmente diferente. Os usuários chegam de automóvel, compram e saem.

O réu, Vinicius da Silva Ernesto Abrão, em seu interrogatório, afirmou que nunca foi preso, nem processado. Trabalha de pintor, ajudante de pintor e na roça. Usa cocaína. Foi internado duas vezes. A última internação faz um tempinho, não muito.

Tem 22 anos. Não teve passagem quando era menor. Foi pego com dois pinos. Tinha pegado os pinos do carro preto. Comprou os dois pinos que pegaram do seu bolso. Comprou do cara do carro preto. Havia outros usuários ali, todos correram e o depoente correu também. Realmente falou para os policiais que estava traficando para manter o vício. Falou isso porque ficou assustado. Nunca tinha passado por situação semelhante. Falou por medo. Não tinha ninguém na rua. Nada mais tem a declarar.

Merece destaque, outrossim, o interrogatório do réu na fase policial – pg. 05: "QUE DISPENSA ADVOGADO PARA ESTE ATO. SUA FAMÍLIA ESTA CIENTE DE SUA PRISÃO. QUE É MORADOR NA CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PARDOP/SP E QUE NA NOITE DE HOJE ENCONTRAVA-SE NO BAIRRO DO VALE REDENTOR NAQUELA CIDADE, NA COMPANHIA DE UM CONHECIDO POPULARMENTE CONHECIDO POR "BAIANINHO". QUE EM COMUM ACORDO COM "BAIANINHO" ESTA COMEÇANDO A VENDER DROGAS NA CIDADE E QUE É TAMBÉM USUÁRIO DE ENTORPECENTES . QUE NESTA NOITE, AMBOS FORAM SURPREENDIDOS POR POLICIAIS MILITARES. QUE DURANTE A AÇÃO POLICIAL, "BAIANINHO" CONSEGUIU ESCAPAR, SENDO APENAS O INTERROGADO CAPTURADO PELA POLICIA MILITAR, CONFESSANDO QUE ESTA VENDENDO DROGAS NA CIDADE, CONTUDO EM SEU PODER FOI APREENHIDO DOIS MICROTUBOS CONTENDO COCAÍNA, DE MODO QUE TINHA INTENÇÃO DE VENDER, TODAVIA AS 33 PEDRAS DE CRACK E UMA PORÇÃO DE MACONHA NÃO ESTAVAM EM SEU PODER E SIM DE "BAIANINHO" E A QUANTIA DE R\$55,00 EM ESPÉCIE E O CELULAR MOTOROLA NÃO SÃO DE SUA PROPRIEDADE. QUE ENCONTRA-SE VERDADEIRAMENTE ARREPENDIDO."

3 -) DA ANÁLISE CRÍTICA E DO DIREITO APLICÁVEL

Ab initio, é preciso consignar a validade do testemunho policial, pois “goza de presunção de credibilidade”.

Quanto às falas dessas testemunhas, à guisa de ter o agente atuado no feito, tenho por oportuno destacar a sua aproveitabilidade, tanto como a de qualquer pessoa. É que o depoimento do policial, em razão de sua condição de agente da Administração Pública, presume-se verdadeiro e merece crédito, mormente porque se mostra firme, coeso e em consonância com o conjunto probatório dos autos. Tal presunção, obviamente, admitiria prova em contrário, que, entretanto, não foi produzida pela defesa.

A credibilidade do depoimento de policiais tem tanta força quanto a de outros indivíduos. O fato de que cabe a eles a atribuição de prevenir e reprimir o crime não tem o condão de invalidar, de per si, a prova decorrente de seus testemunhos.

Por mero preconceito ou suspeita infundada, não deve o Estado-Juiz entender tais depoimentos imprestáveis para lastrear sentença condenatória. O depoimento policial tem plena força probatória, se não houver nenhuma razão plausível, cabalmente comprovada nos autos, para se lhe retirar a credibilidade.

Preceitua o artigo 202 do CPP que “toda pessoa pode ser testemunha”, logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar, sob compromisso de dizer a verdade e, assim, sujeitos às penas do crime de falso testemunho. Além disso, desconsiderar a validade probatória de um

depoimento levando-se em conta, apenas, a profissão de uma pessoa (por exemplo: policial militar ou civil), nada mais é do que contemplar violação ao princípio da igualdade tratando diversamente o valor de uma testemunha por sua profissão, postura essa temerária ao Direito.

O escólio pretoriano bem elucida a questão:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF - 1ª Turma - HC 74.608-0/SP - Rel. Min. Celso de Mello - DJU de 11.04.97, pág. 12.189).

"A SIMPLES CONDIÇÃO DE POLICIAL NÃO TORNA A TESTEMUNHA IMPEDIDA OU SUSPEITA - STF, RTJ 68/64 E 168/199" (Damásio E. de Jesus, Código de Processo Penal Anotado, Saraiva, 19ª Edição, 2002, p. 176 e 182).

Ainda nesse sentido:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. (...) Ordem denegada." (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421). (grifos meus)

Outrossim, é de se ter em conta que se tratando de tráfico de entorpecentes, opera-se a "lei do silêncio", extremamente difícil arrolar testemunhas dispostas a testemunhar contra traficantes.

Nada faz crer que os policiais pudessem ter consigo 33 pedras de crack, 1 porção de maconha e 2 pinos de cocaína, para indevidamente "forjar" cidadão, colocando suas carreiras em risco a fim de aprisionar pessoa com a qual não mantém qualquer desafeto ou problema pessoal.

No caso concreto, os policiais nem estão lotados em São José do Rio Pardo. Portanto, não conheciam o réu e não há nada que possa indicar que tenham agido por sentimentos subalternos dignos de censura.

O réu, a seu turno, não declarou qualquer inimizade ou explanou situações concretas que pudessem indicar que os policiais em questão estariam simplesmente a elucubrar

versão incriminadora para lhe prejudicar.

Nada sugere qualquer equívoco dos policiais em relação à visualização do réu na atividade de traficância desenvolvida, tampouco na confissão apresentada no momento do flagrante.

Ressalte-se, ainda, que o réu confessou perante a Autoridade Policial, tal como reproduzido acima no item 2 - desta fundamentação.

A escusa de que confessou perante os militares por medo não se sustenta, pois nada declarou em relação a eventual temor que teria experimentado de forma justificada na Delegacia de Polícia. Perante a Autoridade Policial teria confessado de forma absolutamente livre e desembaraçada.

A defesa invoca o benefício da dúvida. Contudo, não é o caso de contemplar-se o favor rei.

Conforme artigo 156 do CPP "A prova da alegação incumbe a quem a fizer [...]". Portanto, não se trata de qualquer inversão do ônus da prova, mas sim de aplicação da dinâmica probatória imposta pelo devido processo legal.

Nesse sentido, os ensinamentos de FRAMARINO DEI MALATESTA, o qual afirma que "o princípio ontológico coloca o ônus de prova a cargo da acusação, quando considera as duas asserções contrárias, do acusador e acusado, antes da produção de provas. Mas, desde o momento em que o acusador reuniu as suas provas para sustentar a sua asserção, se o acusado, em contradição à asserção do acusador, emite simples asserção contrária, não faz mais que contrapor uma asserção não provada a uma provada e como esta tem direito de ser tomada como verdadeira de preferência a não provada, sendo a presunção da verdade, neste segundo momento, a favor do acusador, a obrigação da prova incumbe ao acusado" (A Lógica das Provas em Matéria Criminal, Campinas: Conan 1995 v. I p. 45-146 - destaque do Juízo).

Destarte, o que se tem objetivamente nos autos é a narrativa consistente de dois policiais que descrevem atos típicos de traficância do réu, a confissão em Delegacia do próprio réu e sua posterior negativa em Juízo, ou seja, não há contraprovas para que este Juízo possa embasar conclusão no sentido de que existe outra versão dos fatos mais favorável ao réu do que aquela estampada na denúncia.

Diante de tal panorama, não se ressente este Juízo de qualquer dúvida a respeito da procedência da ação penal.

Presente a tipicidade delitiva na forma capitulada na denúncia e não havendo justificativas ou dirimentes capazes de afastar a antijuridicidade da conduta e culpabilidade do réu, a condenação é medida necessária para a concretização dos escopos de prevenção geral positiva e prevenção especial colimados pelo sistema punitivo, além de restabelecer o princípio da prevalência do Direito e atestar a vigência da norma penal violada.

4 -) DO VEREDITO E DOSIMETRIA DA PENA

Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia de págs. 72/74 para CONDENAR VINÍCIUS DA SILVA ERNESTO ABRÃO pela prática do crime capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, passando a dosar-lhe a pena, nos termos do artigo 68 do Código Penal e artigo 42 da Lei de Drogas.

Analizadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, observa-se que o modus operandi não recomenda que seja acentuada a pena, pois a culpabilidade é normal à espécie.

Poucos elementos foram coletados acerca de sua conduta social e personalidade, razão pela qual não influenciam negativamente a dosimetria. Além disso, deixo transparecer que tais circunstâncias judiciais se analisadas em detrimento do réu evidenciam acolhimento do "direito penal de autor", fenômeno indesejável e antigarantista que não conta com o aval deste Juízo.

Na análise determinada pelo art. 42 da Lei de Drogas tem-se que o critério "quantidade" compreende duas variáveis:

1ª O peso, massa, das substâncias propriamente ditas não recomenda acréscimo, pois a apreensão foi de 8,8 gramas de crack (pg. 141), 4,03 gramas de maconha (pg. 144) e 0,42 gramas de cocaína (pg. 147).

2ª A diversidade, variedade das substâncias, pois em "quantidade" de drogas podemos ter pequenas ou grandes porções de 1,2,3 ou mais drogas diferentes.

A quantidade-massa é insuficiente para justificar qualquer acréscimo. No entanto, a quantidade-diversidade autoriza maior rigor na sanção, pois tendo à sua disposição três tipos diversos de drogas o réu poderia atingir maior "clientela", o que significa maior periculosidade.

O motivo do delito está albergado na própria tipicidade da traficância enquanto atividade mercantil para obtenção de lucro ilícito.

As circunstâncias do delito não destoam daquelas em que ocorrem crimes desta natureza, ao passo que não há elementos para aferir se as consequências foram graves.

Assim, fixo a pena base para o crime capitulado no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006, 1/6 acima do mínimo legal de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias-multa.

Presente a agravante do artigo 61, II, "j" do Código Penal, uma vez que o crime foi cometido em período de calamidade pública, declarada pelo Governo Federal e Estadual em decorrência da pandemia do Covid-19.

Registre-se que há total pertinência entre a incidência desta agravante e a situação de calamidade em vigor. Vivemos uma calamidade pública sanitária, encontrando-se a saúde pública enormemente fragilizada, com milhões de infectados pelo coronavírus e centenas de milhares de mortos (mais de seiscentos mil nesta data).

O tráfico de drogas é conduta que ataca exatamente a saúde pública.

Indesculpável que o réu, insensível à realidade calamitosa experimentada pelo país e pelo mundo, pretenda traficar maconha, crack e cocaína aviltando o bem jurídico deveras fragilizado.

Ademais, não se extrai do disposto na alínea "j" do inciso II do art. 61 do Código Penal, qualquer outra exigência senão a da prática do crime em situação de calamidade pública.

A voluntas legis foi de, sabiamente, agravar a pena daqueles que a despeito de uma situação de calamidade, atacam o rigor da norma penal avançando sobre bens jurídicos alheios, individuais, difusos ou coletivos.

Todavia, a confissão do réu em solo policial foi considerada para fins de convicção judicial de modo que incide a súmula 545 do E. STJ, compensando-se a agravante supra com a atenuante da confissão.

Inviável o reconhecimento do privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, diante da certidão de pgs. 132/133 que demonstra que o réu foi beneficiado com liberdade provisória por flagrante de suposta prática de tráfico de drogas em decisão proferida aos 17.09.2021.

Há elementos objetivos hábeis a indicar que o réu vem se dedicando a atividades criminosas, o que também impede a concessão do privilégio, pois pacífica a jurisprudência do E. STJ no sentido de que inquéritos policiais e ações penais em andamento, bem como condenações por fatos posteriores podem obstar a aplicação do benefício descrito no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, porquanto demonstra a prática reiterada de condutas nocivas, bem como a incursão do acusado em atividades criminosas (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 1.594.419/RS (2019/0294417-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca. j. 17.12.2019, DJe 19.12.2019).

E ainda: "A teor do entendimento firmado na Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o EREsp nº 1.431.091/SP, em sessão realizada no dia 14.12.2016, inquéritos policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas." (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 1.575.466/ES (2019/0264981-9), 5ª Turma do STJ, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca. j. 19.11.2019, DJe 03.12.2019)

Inaplicável, por outro lado, a majorante do inciso III do art. 40 da Lei de Drogas. A denúncia sustenta que "VINÍCIUS praticou o crime na Praça João Batista Ribeiro de Lima, recinto onde se realizam diversões de qualquer natureza." - pg. 73.

O inciso III do art. 40 da Lei 11.343/2006 não menciona "praça" e sim, "recintos". Observe-se:

"III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos;" (destaque do Juízo).

A cidade de São José do Rio Pardo é relativamente pequena. Tem cerca de 55.000 habitantes. Existem diversas praças, escolas, locais de atendimento público espalhados pela urbe, de modo que encampar a tese ministerial também ocasionaria que em praticamente todos os tráficos de entorpecentes nesta cidade ensejassem a incidência da majorante em verdadeira e inaceitável aplicação de responsabilidade penal objetiva, violando o finalismo penal. Basta ver a quantidade de denúncias com a mesma causa de aumento de pena. Estariam livres apenas, em tese, traficantes que se utilizassem da zona rural.

Há praças de maiores ou menores dimensões espalhadas pelo centro e bairros da cidade. Apenas na parte central são vizinhas e quase contíguas as praças do Epidauro; a praça dos 3 Poderes e a praça Cândido Ribeiro, todas circundadas por escolas nas adjacências.

Não se pode emprestar qualquer amplitude ao termo "praça" para confundi-lo com "recinto onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza", pois com apoio léxico tem-se que "recinto é local cercado ou fechado" (Dicionário Aurélio, Ed. Positivo, 3.ed, 2004, vocábulo "recinto" p. 1709).

Ao contrário de "recinto", uma praça é um local geralmente amplo e aberto, bem de uso comum. Aumentar a pena neste caso seria proceder com clara analogia in malam partem.

Assim, o fato de que o réu tenha sido avistado em uma "praça" não autoriza a exasperação de pena na forma pretendida pelo Ministério Público, uma vez que não se trata de "recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza".

O propósito do legislador foi o de reprimir de forma mais severa aquele agente que se aproveita dos locais de aglomeração de pessoas para implementar o seu negócio ilícito. Isso não significa que se enquadre no inciso III, do artigo 40 da Lei nº 11.343/2006, toda e qualquer conduta de tráfico de entorpecentes nos ambientes referidos no aludido inciso.

Para a caracterização da referida causa de aumento, mister que o agente pretenda dolosamente utilizar ambientes com um maior agrupamento natural de pessoas para desenvolver com mais facilidade a mercancia ilícita de entorpecentes, sob pena de violação do finalismo penal e criação de hipótese de responsabilidade penal objetiva.

Por fim, ambos os policiais militares salientaram que não havia famílias e pessoas de bem por ali. A praça é pouco iluminada e apenas os traficantes permanecem nas imediações aguardando os usuários que se aproximam.

Idêntico foi o entendimento no julgamento da apelação criminal 0000713-69.2018.8.26.0575 desta mesma vara judicial, cuja relatoria ficou ao encargo do Excelentíssimo Desembargador Paiva Coutinho - 11ª Câmara de Direito Criminal, j. 04.03.2021.

Torno em definitiva a pena encontrada na primeira fase - 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias-multa.

Fixo o regime FECHADO para início do cumprimento de pena, em consideração ao montante de pena aplicada e o caráter hediondo da conduta. Levo em consideração, ainda, o fato de que o réu foi beneficiado com liberdade provisória e voltou a traficar em curto espaço de tempo, demonstrando que regimes diversos do fechado ou qualquer benefício que viabilize seu contato com o meio aberto é insuficiente para romper a "teia" criminoso na qual está envolvido, pois permanece em contato com fornecedores de maior envergadura assim como com sua "clientela".

O dia-multa será calculado no valor mínimo unitário previsto no art. 43 da Lei 11.343/2006, por não haver motivo informado nos autos que justifique sua majoração.

Nos termos dos artigos 804 e 805 do CPP, CONDENO o réu ao pagamento das custas processuais que fixo em 100 UFESP's, ficando a cobrança suspensa na forma do § 3º do art. 98 do NCPC c.c art. 3º do CPP.

Considerando presentes os requisitos e fundamentos que levaram à decretação da prisão preventiva do réu, mantenho sua custódia cautelar, indeferindo a pretensão de apelar em liberdade. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Expeça-se

guia de execução provisória.

Patrocinado por advogado dativo arbitro os honorários, conforme regras do convênio. Oportunamente, expeça-se certidão.

Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes providências:

- 1 -) Expeça-se guia de execução definitiva, recomendando-se o sentenciado;
- 2 -) Proceda-se ao recolhimento dos valores atribuído a título de pena pecuniária, em conformidade com o disposto no artigo 686 do Código de Processo Penal;
- 3 -) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia desta decisão, para cumprimento do disposto nos artigos 71, §2º do Código Eleitoral c/c inciso III do artigo 15 da Constituição da República;
- 4 -) Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias;
- 5 -) Como a quantia apreendida - R\$ 55,00 - está intrinsecamente vinculada à prática delitiva, à míngua de comprovação de sua origem lícita decreto seu perdimento, nos termos da lei.
- 6 -) Comunique-se ao i. Juízo da 2ª Vara a condenação aqui imposta para os fins do processo 1500736-33.2021.8.26.0575, apresentando nossas homenagens.

P.I.C

Sao Jose do Rio Pardo, 08 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA